

1501090-89.2021.8.26.0306

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... já é conhecido dos meios policiais por tráfico, assim como Wellington. Não sabe se algum é usuário. Wellington resistiu para evitar a abordagem. Ele se debatia a todo momento. Tiveram que usar força física necessária. Só usaram a força porque ele tentou agredir os policiais. Ele saiu todo alterado e partiu para cima deles. Usaram os meios não letais para imobilizá-lo. Não sabem dizer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Monsenhor Angelo Angioni, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501090-89.2021.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501090-89.2021.8.26.0306

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081548/2021 - DEL.POL.JOSE

BONIFACIO, 20579264 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

FERNANDO HENRIQUE APARECIDO FORTE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE APARECIDO FORTE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal, e WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO FORTE, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 28 de setembro de 2021, por volta de 02h10, na Av. Luís Pereira Lima, nesta cidade e Comarca de José Bonifácio, FERNANDO HENRIQUE APARECIDO FORTE, com dados de qualificação às fls. 11, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO FORTE, com dados de qualificação às fls. 16, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário público competente para executá-lo. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO FORTE, com dados de qualificação às fls. 16, guardava e tinha em

depósito, para consumo pessoal, 3,94g (três gramas, novecentos e quarenta miligramas) de cocaína, acondicionada em 01 (uma) porção, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de exame químico-toxicológico de fls. 19/21).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, policiais militares em patrulhamento pela via pública tentando identificar os autores de um furto a um estabelecimento comercial ocorrido naquela noite, visualizaram e decidiram abordar o condutor do veículo GM/Corsa, placas CSX-7022, que ao notar a aproximação policial, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga pelas vias públicas.

Após perseguição, lograram efetuar a abordagem somente do passageiro do veículo, identificado como sendo o denunciado Wellington, que ofereceu resistência, e tentou agredir os policiais, tendo sido necessário o uso de força física moderada contê-lo.

O condutor do veículo, apesar de ter se evadido pelo córrego, foi identificado como o denunciado Fernando.

Em revista veicular, localizou-se no console do automóvel, uma porção de cocaína pertencente ao denunciado Wellington, que alegou ser para seu uso pessoal.

Em audiência de instrução, a denúncia foi recebida, foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados.

O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa pediu a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há nulidades a serem sanadas, nem preliminares a serem analisadas.

A pretensão penal punitiva é procedente.

Encerrada a instrução processual, a materialidade do delito restou evidenciada através do boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), receituário médico (fl. 06), termos de declarações (fls. 11; 16), auto de entrega (fls. 12/13), termo de depoimento (fls. 17/18), laudo pericial (fls. 19/21), relatório final (fl. 22), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Fernando Henrique Milanez (testemunha de acusação) disse que estavam em patrulhamento, para coibir furtos na cidade. Ouviram um alarme disparado e foram parados por um comerciante. Verificaram e viram que o telhado estava arrombado. Vistoriaram o local e não encontraram o indivíduo. Tinham informações que um Corsa praticava os furtos. Viram o veículo. Deram sinais sonoros e luminosos e o carro se evadiu, entrando em uma rua sem saída. O motorista, saiu correndo e foi em direção às casas, pulando os muros. Abordaram o passageiro, que estava muito nervoso. Ele partiu para cima da guarnição, usando a força necessária para algemá-lo. Dentro do veículo tinham uma faca, roupas e um celular. Tentaram localizar Fernando, mas não conseguiram. Levaram Wellington ao PS. Wellington ofereceu resistência. Fernando se evadiu na abordagem. Fernando desobedeceu a ordem de parada. Ele desembarcou do carro e correu pelo córrego. Tinha uma substância entorpecente dentro do veículo, mas não soube precisar de quem era. Wellington desembarcou do carro alterado e partiu para cima da guarnição. No momento, só estavam os dois policiais. Fernando já é conhecido dos meios policiais por tráfico, assim como Wellington. Não sabe se algum é usuário. Wellington resistiu para evitar a abordagem. Ele se debatia a todo momento. Tiveram que usar força física necessária. Só usaram a força porque ele tentou agredir os policiais. Ele saiu todo alterado e partiu para cima deles. Usaram os meios não letais para imobilizá-lo. Não sabem dizer se ele tinha feito uso de drogas. Não pode afirmar. Não tiveram contato com Fernando naquele, pois não o localizaram. Não se recorda se Wellington confirmou se a droga era dele. Finalizada a abordagem, levaram Wellington ao PS e, apenas após, foram ao plantão policial.

Ronaldo Tonelli (testemunha de acusação) disse que estavam em patrulhamento sobre um furto. Constaram que o teto estava arrombado e não localizaram ninguém.

Orientaram-no a procurar a polícia civil, para fazer a ocorrência. Em patrulhamento, viram o veículo Corsa, conduzido por Fernando, sendo Wellington passageiro. Ao dar o sinal de parada, ele tentou se evadir e entrou em rua sem saída. Fernando abriu a porta do carro e correu. Wellington não quis ser abordado e reagiu com violência. Tiveram que usar força para contê-lo. No veículo, encontraram porção de cocaína, faca e vestes. Conduziram Wellington para a Santa Casa. Fernando era o condutor do veículo. Wellington não quis ser abordado e usar de força contra os policiais. Na versão de Wellington, a porção era dele. Ele disse que é usuário. Na hora da abordagem, estava a viatura do depoente e do sargento. Eram 4 pessoas. Depois, fizeram diligências para localizar o réu. Deram sinal sonoro e luminoso da viatura.

Fernando Henrique Aparecido Forte (réu) disse que 24 anos. Está desempregado. Não tem fonte de renda. É solteiro. Tem um filho menor de idade, 02 anos e 05 meses. Disse que estavam indo ver um serviço do irmão. No caminho, virou em uma rua e a viatura virou logo atrás. Parou e os policiais mandaram sair do carro. Ficaram ajoelhados na frente do carro. Em seguida, chegou outra viatura e começaram a agredi-los. Falaram que iriam matá-los. Era um lugar escuro e na beira do rio. Resolveu correr. Já conhecia os policiais. O policial Milanez persegue o depoente. Já discutiu com Milanez em uma abordagem. Eles já começaram a agredir. O irmão está com a costela quebrada. Foi à delegacia depois, para retirar os pertences. Prestou o depoimento na delegacia (fl. 11). É usuário de drogas, de cocaína. Não tinha usado drogas naquele dia. Tinha uma porção de cocaína. Os dois são usuários. A porção era dele, para uso. Não resistiram.

Wellington Henrique Aparecido Forte (réu) disse que tem 22 anos. Está fazendo bicos na seringueira. Ganha por quinzena, 1200 reais por quinzena. É solteiro. Não tem filhos. Disse que estava indo trabalhar com o irmão. A viatura fez a abordagem. Eles deram a ordem de parada e eles pararam. Ficaram no chão ajoelhados por meia hora, esperando a outra viatura. Quando a outra viatura chegou, eles agrediram os réus. Não fizeram nada. Eles já chegaram agredindo Fernando ficou no local. Assim que os policiais chegaram, eles começaram a agredi-lo e ameaçá-lo de morte. Ele entrou em desespero e correu. Conhece Milanez, que persegue os dois a tempos. Tiveram problemas com o depoente quando era menor de idade. Nunca chegou a brigar ou discutir com Milanez. Falou a mesma versão na delegacia. No carro, tinha uma porção de cocaína, que era para o uso do depoente. Tinha a faca, que era usada na seringueira. Não contou para o médico e para o delegado. O policial falou que, se falasse algo para o médico, iria conversar com ele, ameaçando-o. Não tinha mais ninguém no local, além do depoente e dos policiais. Não tem problema com Ronaldo, nem o conhece. Na delegacia, foi ouvido pelo escrivão de polícia.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Durante o inquérito policial, o réu Fernando Henrique confessou os fatos. Declarou que: "no dia dos fatos estava dirigindo o veículo GM/Corsa e quando viu o sinal emitido pelos policiais militares para a parada, no mesmo instante parou o veículo e desceu, mas que por receio pois seu carro estava irregular, acabou fugindo a pé do local, ficando apenas seu irmão. O declarante informa que no carro havia uma porção de cocaína, pertencente à seu irmão, pois o mesmo é usuário, algumas peças de roupa pertencente ao declarante e dois celulares, um pertencente ao declarante e outro ao seu irmão, além de uma faca, pertencente ao declarante pois trabalha na seringueira e a utiliza no serviço. O declarante informa que no dia dos fatos não veio até a Delegacia de Polícia, tendo sido apenas seu irmão apresentado para o registro da ocorrência" (fl. 11).

Por sua vez, o acusado Wellington confirmou ser o proprietário da droga. Porém, nada mencionou sobre ter resistido à abordagem, declarando que foi agredido fisicamente pelos policiais. Informou que: "no dia dos fatos seu irmão Fernando estava dirigindo o veículo GM/Corsa e que a viatura da Polícia Militar emitia sinais para a parada tendo seu irmão Fernando parado o carro no mesmo instante, mas que seu irmão evadiu-se do local a pé, tendo ficado apenas o declarante. O declarante informa que foi agredido e fraturou a costela, tendo que ficar noventa dias afastado de seu serviço. O declarante informa que no carro havia uma porção de

cocaína, de sua posse, pois o mesmo é usuário, algumas peças de roupa pertencente à seu irmão e dois celulares, um pertencente ao declarante e outro ao seu irmão, além de uma faca, pertencente a seu irmão, pois o mesmo trabalha na seringueira e a utiliza no serviço. O declarante informa que no dia dos fatos foi conduzido até a Santa Casa Local para constatação de lesões e que posteriormente foi conduzido até a Delegacia de Polícia para registro da presente ocorrência". (fl. 16).

Na fase judicial, o réu Fernando negou a prática do delito. Por sua vez, Wellington confirmou que trazia uma porção de cocaína para seu uso, negando a prática de resistência.

Entretanto, a versão dos réus é inverossímil e não merece prosperar.

Os réus declararam que os policiais faltaram com a verdade em juízo e que ambos teriam sido agredidos por policiais. Questionados, declararam que Milanez os estaria perseguindo na cidade. Porém, não indicaram qualquer problema pessoal com o policial Tonelli. Referido policial prestou declaração em sentido diverso dos acusados, comprovando todos os fatos narrados na denúncia. Wellington também declarou que não tinha nenhum problema pessoal com o escrivão de polícia que colheu seu depoimento na fase inquisitorial. Portanto, não há motivos para crer que o escrivão de polícia tenha, dolosamente e com a finalidade de prejudicar os réus, alterado a versão prestada por quaisquer dos acusados. E, na delegacia de polícia, os réus prestaram depoimento totalmente diverso do ora apresentado.

Além da confissão extrajudicial dos réus, a versão dos policiais é harmoniosa com as demais provas e indícios colhidos. Em juízo, os agentes públicos confirmaram a prática dos delitos pelos acusados, nos exatos termos narrados na denúncia.

Anoto que não se questiona a idoneidade e o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, uma vez que se admite a condenação com base em depoimentos de policiais, quando a versão apresentada é verdadeira e em consonância com os elementos dos autos.

É rebatida a tese da imprestabilidade do depoimento de policiais. Com efeito, conforme amplamente decidido, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado.

Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372). A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÕES CRIMINAIS Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas Palavra das vítimas Relevância Reconhecimento em solo policial e reconhecimento pessoal em juízo Palavra dos policiais Validade Precedentes Insubsistente a alegação de insuficiência probatória Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de forma correta Pena-base fixada acima do mínimo legal por decisão motivada e bem fundamentada - Majoração das penas na terceira fase Presença de duas causas de aumento - Concurso de agentes e emprego de arma - Princípio da individualização da pena - Regime inicial fechado Adequado ao caso concreto APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502359-43.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que pretende a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prisão em flagrante de posse de 33,3g de maconha, 43g de cocaína, 22,5g de crack e 1 litro de lança-perfume. Versão defensiva inverossímil e isolada. Impossibilidade de furar credibilidade à palavra dos policiais apenas por sua função. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas, atenuadas ao piso pela menoridade relativa. Afastamento do redutor com

fundamentação inidônea. Mera menção à existência de registros de atos infracionais insuficientes para demonstrar dedicação ao crime. Penas reduzidas a 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa. Possibilidade de regime inicial aberto e substituição da primeira por restritivas de direitos. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500192-38.2021.8.26.0545; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Quanto ao réu Fernando, vê-se que o réu desobedeceu à ordem legal clara de parada emitida pelos policiais militares e empreendeu fuga a pé, cometendo o delito previsto no artigo 330 do Código Penal. Não foram apontados motivos pelos quais os policiais imputariam falsa acusação ao réu.

Logo, todos os elementos produzidos corroboram a tese acusatória prevista na denúncia. Ressalto que o fato de o réu estar com medo de ser preso, por estar por estar com o carro em situação irregular, não afasta a tipicidade penal, nem justifica o descumprimento de ordem legal.

Referido delito objetiva a manutenção da autoridade e do respeito devidos às ordens legais emitidas pelos funcionários públicos em geral. A desobediência à referida ordem em suma, significa não acatar o comando legal recebido, mas sem o emprego de grave ameaça ou de violência. É realmente a simples desobediência, como por exemplo "recusa em apresentar documentos do veículo, principalmente depois de um acidente de trânsito; recusa no cumprimento de mandado judicial; recusa em parar em patrulhamento de trânsito" (CAMPOS, 2016, p. 771).

Neste caso concreto, os policiais deram ordem de parada ao réu, de forma clara, o que não foi obedecido pelo acusado. Esse juízo não desconhece o entendimento jurisprudencial segundo o qual a desobediência à ordem legal de parada configura tão somente infração administrativa. No entanto, atualmente, prevalece o entendimento que o fato configura a prática do delito do artigo 330, do Código Penal, sem prejuízo das sanções administrativas, quando a ordem é emitida por policiais militares, e não pela Autoridade de trânsito.

É o teor dos recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Art. 330 do Código Penal. Desobediência. Sentença de procedência. Reforma: Impossibilidade. Tipicidade da conduta. Aplicação correta do art. 330 do CP, em detrimento do art. 195 do CTB, que prevê mera sanção civil (multa). Desobediência que se deu ao não atender ordem de parada, emanada de policial durante patrulhamento de rotina. Instâncias administrativa e criminal independentes. Pena criteriosamente aplicada e substituída. Condenação mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0003189-68.2015.8.26.0322; Relator (a): Heber Gualberto Mendonça; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Lins - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Direção de veículo automotor sem habilitação - Desobediência - Réu que confessa estar conduzindo veículo automotor sem possuir habilitação - Ordem de parada feita por policiais militares e frontalmente desobedecida pelo réu - Fuga com o veículo - Geração de perigo de dano na condução do veículo consistente em desobediência reiterada de sinalizações de trânsito de parada obrigatória vindo ao final a colidir com outro veículo - Pena adequadamente dosada - Recurso desprovido (TJSP; Apelação Criminal 0002116-82.2017.8.26.0066; Relator (a): Carlos Fakiani Macatti; Órgão Julgador: Turma Criminal; Foro de Barretos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

Além disso, também está comprovada a prática do delito do artigo 329, CP, pelo acusado Wellington. Sobre o crime de resistência, ensina Celso Delmanto que "o núcleo é opor-se, que tem o sentido de resistir. O agente resiste à execução do ato legal, isto é, ato que está sendo executado no momento. Para a configuração do delito é necessário que a oposição seja mediante violência ou ameaça a funcionário (ou a quem lhe esteja prestando auxílio)" (DELMANTO, Celso. DELMANTO, Roberto.

DELMANTO JÚNIOR, Roberto. DELMANTO, Fábio M. De Almeida. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 816).

Na situação em análise, ficou demonstrado que os policiais deram ordem de abordagem. O réu, então, ofereceu resistência, tentando agredi-los, tendo sido necessário o uso de força física para contê-lo.

Assim agindo, o acusado se opôs, com violência, aos procedimentos de abordagem a serem realizados pelos agentes públicos. Destaco que a atuação da Polícia Militar foi totalmente regular, demonstrando o estudo e preparo para realização da abordagem. Com efeito, não há quaisquer elementos a indicar que houve abuso de autoridade ou uso de força física/violência contra os envolvidos. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, de fato, faz-se necessário que os agentes tenham controle de toda a situação.

Irregular, portanto, é a conduta do réu que tentou burlar as ordens dos agentes públicos, mediante violência. Ambos os policiais são categóricos em afirmar que Wellington tentou agredi-los, em razão do procedimento de abordagem.

Com relação à posse de substância ilícita para uso pessoal, o acusado Wellington confessou a prática delitiva, dizendo que a porção da droga se destinava ao seu consumo. Na mesma esteira, é o depoimento dos policiais. Portanto, todos os elementos confirmam que o réu trazia o entorpecente para o próprio consumo.

Cumprе ressaltar que a tipificação, pelo ordenamento, do porte de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade. Não há que se falar em mácula ao princípio da alteridade, uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, e não a integridade física ou psíquica do usuário.

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DESUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFINA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I-Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II-A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornara conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III-No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV-É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V-A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI-Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII-Habeas corpus prejudicado" (STF.HC 102940 /ES. Primeira Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:15/02/2011).

Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos Tribunais Superiores.

Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06-nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção-não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime-como o fez o art. 28 da L. 11.343/06-pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora

(CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO/ RJ-RIO DE JANEIRO-QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO-Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento:13/02/2007-Órgão Julgador: Primeira Turma).

Configurado, pois, os delitos narrados na denúncia.

Verifico que, à época dos fatos, os réus eram primários e portadores de bons antecedentes. (fls. 27/30), pois não possuíam condenação com trânsito em julgado anterior à data dos fatos. Reconheço, em favor de Fernando, a atenuante da confissão espontânea. Embora o réu tenha se retratado judicialmente, confessou o delito durante o inquérito policial, confissão esta que foi utilizada para fundamentar a condenação. Quanto ao réu Wellington, reconheço a atenuante da confissão espontânea apenas em relação ao delito do artigo 28, da Lei de drogas. Passo à dosimetria da pena.

FERNANDO HENRIQUE APARECIDO FORTE

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que, na primeira fase, o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar fixado (Súmula 231, do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno a pena definitiva em 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, devidamente atualizado.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena de detenção.

Em obediência ao artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa (artigo 44, §2º, CP), consistente no pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

Para não haver dúvidas no momento da execução, o réu deverá pagar 20 dias-multa (10 dias em cumulação à pena privativa e 10 dias em substituição à pena privativa).

Fica prejudicada a análise do artigo 77, do Código Penal.

WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO FORTE

Artigo 28, da Lei 11.343/06

Na primeira fase, o acusado não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pelo que fixo a pena base em advertência.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Mantenho a pena mais branda já fixada, qual seja, a advertência.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Mantenho a pena no patamar fixado, isto é, advertência.

Artigo 329 do Código Penal

Na primeira fase, respeitado o sistema trifásico e analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar fixado (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 02 meses de detenção.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 69, CP. Somo as penas, totalizando 02 meses de detenção e advertência.

Para o início do cumprimento da pena, fixo o regime aberto, considerando que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Ausentes elementos sobre o tempo de prisão provisória do acusado e sobre o cumprimento dos requisitos subjetivos para a progressão do regime, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência à pessoa.

Possível a concessão de sursis, nos moldes do artigo 77, do Código Penal. Porém, afasto-o, pois não pode um benefício ser mais gravoso que a execução da própria pena, especialmente de curta duração e que pode ser extinta em breve lapso temporal, não tendo que se sujeitar o condenado ao longo período de prova de dois anos. Não se mostra razoável. Nestes termos:

APELAÇÃO. Artigo 129, §9º, Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria acertada.

Regime aberto adequadamente imposto. Sursis afastado ex officio porque em se tratando de benefício não pode ser mais gravoso que a própria execução da pena.

PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação nº 0002388-11.2007.8.26.0007, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Camargo Aranha Filho, j. 25/08/2016).

Lesão corporal decorrente de violência doméstica - Absolvição - Impossibilidade Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Pena e regime mantidos - Afastamento do "sursis" - Regime aberto mais benéfico - Recurso provido em parte (Apelação nº 0000783- 94.2016.8.26.0595, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador FREITAS FILHO, j. 06/09/2017).

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DOSIMETRIA E REGIMEPRISIONAL ADEQUADOS - AFASTAMENTO DO SURSIS POR SER PREJUDICIAL AO RÉU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação nº 0024975-58.2014.8.26.0564, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Nuevo Campos, j. 04/08/2017).

Com efeito, a depender da penalidade imposta, mormente nos casos de privação de liberdade de curta duração, e em regime aberto, é-lhe mais favorável cumprir de pronto a pena, a sujeitar-se a longo período de dois anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR:

1) FERNANDO HENRIQUE APARECIDO FORTE, portador do RG: 49.223.853, nascido em 14/08/1997, natural de José Bonifácio - SP, filho de Dorivaldo Ferreira Forte e Adriana Aparecida dos Santos, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 330, do Código Penal. Em obediência ao artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa (artigo 44, §2º, CP), consistente no pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

2) WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO FORTE, portador do RG: 48.496.921, nascido em 11/04/2000, natural de José Bonifácio - SP, filho de Dorivaldo Ferreira Forte e



Adriana Aparecida dos Santos, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime ABERTO, e à pena de ADVERTÊNCIA, como incurso nas sanções do artigo 329, do Código Penal, e artigo 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. Condene, ainda, os réus ao pagamento das custas do processo, na forma da Lei 11.608/03, com as ressalvas da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3º, novo CPC, que revogou a Lei 1060/50).

Os réus poderão recorrer em liberdade por este processo, ausentes os requisitos do artigo 312, CPP. Ressalte-se que o sentenciado está preso por outro processo.

Não há vítima a ser comunicada, nem dano material a ser indenizado.

Após o trânsito em julgado: comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, III, da Constituição Federal; oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; extraiam-se as guias de execução definitiva, observando-se o regime inicial fixado na condenação, se for o caso.

Intimem-se, pessoalmente, os réus.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

José Bonifacio, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA